

1502404-91.2022.8.26.0320

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ricardo Truite Alves

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... (intenção) mercantil da posse e da guarda da droga como tráfico consumado. O mero fato de o agente guardar ou ter em depósito drogas, ainda que a mando de terceiros, mesmo que sem intuito de lucro, configura o crime de tráfico de drogas, pois o tipo penal prevê como tráfico as condutas de guardar e ter em depósito, ainda que gratuitamente (art. 33, caput, Lei de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

1ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502404-91.2022.8.26.0320 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502404-91.2022.8.26.0320

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 2201337/2022 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 26341740 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2201337 - DISE-DEL.SEC.LIMEIRA, 2201337/2022 - DISE - Delegacia de Investigações Sobre

Entorpecentes de Limeira

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Luana Nogueira Bernardo e outro

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ricardo Truite Alves

Vistos.

LUANA NOGUEIRA BERNARDO e ALISON EDUARDO DE CAMPOS ARAUJO, qualificados nos autos, estão sendo processados como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal.

Conforme consta do incluso inquérito policial, no dia 26 de julho de 2022, por volta da 0h30min, na Rua Irineu Casemiro, nº 107, Parque Abílio Pedro, neste município e comarca, os acusados guardavam e traziam consigo, com intuito de tráfico ilícito, drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal, a saber, 25 (vinte e cinco) porções de Erythroxylum coca, conhecida como cocaína, pesando 11,73, conforme auto exibição e apreensão e auto de constatação preliminar, para venda a consumo de terceiros.

Ao que se apurou, na ocasião supramencionada, os denunciados guardavam e traziam

consigo, na residência de Luana, droga para fins de comercialização.

Ocorre que policiais militares realizavam operação especial em local conhecido como ponto de tráfico ilícito de drogas, ocasião em que surpreenderam a denunciada, que guardava no pé do portão de sua moradia, em companhia do denunciado, vinte e quatro das porções de droga acima indicada.

Durante revista pessoal por agente público feminina, foi encontrada em posse de Luana a quantia equivalente a R\$40,00 (quarenta reais) em dinheiro. Logo após, em revista pessoal do denunciado, os policiais militares encontraram um flaconete preenchido com cocaína de posse dele, bem como R\$110,00 (cento e dez) reais em dinheiro, oportunidade em que ambos os denunciados foram presos em flagrante delito.

Oferecida à denúncia, determinou-se a notificação dos réus para que apresentassem defesas preliminares (fls. 203 e 220), que vieram aos autos (fls. 228/235).

A denúncia foi recebida em 20 de setembro de 2022 (fls. 251).

Durante a audiência de instrução, debates e julgamento, foram ouvidas as testemunhas, bem como interrogados os réus ao final (mídia).

Encerrada a instrução, as partes manifestaram-se.

Alegações finais escritas do Ministério Público (fls. 318/326) e da Defesa de Alison (fls. 329/331) e Luana (fls. 338/344).

É o breve relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Não há preliminares pendentes de apreciação.

O pedido condenatório é parcialmente procedente.

É caso de condenação da acusada Luana e desclassificação quanto ao corréu Alison.

A materialidade restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 03), boletim de ocorrência (fls. 10/12), auto de exibição e apreensão (fls. 13), laudo pericial com resultado positivo para cocaína (fls. 127/129), bem como pela prova oral colhida no curso da persecução penal.

A autoria é certa e segura quanto à corré Luana na imputação descrita na denúncia.

Em solo policial, o acusado Alison negou a prática do delito. Disse que conviveu com Luana durante quatro anos e que no dia havia ido visita-la. Alegou que o dinheiro encontrado em sua posse obteve de sua genitora (fls. 06).

Em Juízo, o denunciado disse que tem 25 anos. Trabalha com reciclagem. Estava na casa de Luana, não havia mais relacionamento entre eles. Ela descobriu que ele se envolveu com outra pessoa. Foram conversar a respeito disso. No momento da conversa foram abordados pelos policiais militares. Eram duas viaturas. Explicou onde morava. Foram questionados. Disse aos guardas que estavam resolvendo o relacionamento. Tinha em seu poder uma porção de cocaína e dinheiro do seu trabalho. Não tem conhecimento das 24 porções de cocaína encontradas. Estava separado de Luana, não sabia o que ela fazia. Ficou longe dela durante a abordagem, os policiais acharam que ela mentia para livra-lo. Mora em outro local, fica mais pra baixo. Não conhecia os guardas. É usuário de drogas e havia comprado uma porção para uso. Os policiais disseram a ele que o local era ponto de tráfico de

entorpecentes, mas não sabia dessa informação. Tem antecedentes criminais, já foi condenado por tráfico. Não viu qualquer encontro da sacola contendo porções de cocaína. Luana foi levada em outra viatura. Um outro rapaz que descia também foi abordado, mas depois liberado. Viu os guardas entrando na casa de Luana (mídia).

Em solo policial, a acusada Luana disse que havia encontrado os flaconetes de cocaína, mas que iria entregar para a polícia. Afirma que conviveu com Alison durante 04 anos, mas que não tiveram filhos (fls. 07).

Em Juízo, a denunciada Luana disse que tem 31 anos. É ourives. Não tem antecedentes criminais. Largou de Alison. Chamou ele para conversar na sua casa naquele dia por ele estar com uma outra mulher. Foram enquadrados pelos guardas. Havia um menino descendo a rua. Esse garoto foi liberado pelos policiais. Não sabe o que tinha em poder desse rapaz. Não sabe nada a respeito de pacote contendo cocaína. Não viu o encontro de qualquer pacote. Estavam numa distância longe de casa, estavam na vizinha, era um outro muro. O policial disse que achou um pacote e que eles seriam presos. Não sabe se Alison tem algum envolvimento com as drogas localizadas. Tinha quarenta reais em seu poder, era dinheiro da patroa. Não se recorda se Alison tinha dinheiro, muito menos droga. Não conhecia os agentes públicos. Não sabe se o local que mora é ponto de tráfico. Ficou nervosa no momento da prisão, não sabe se falou do encontro de drogas numa área verde. Viu o policial tirando uma porção do bolso de Alison. Não viu as 24 porções de cocaína, muito menos o encontro desses entorpecentes. Os policiais não disseram o motivo da prisão, eles teriam apenas que acompanhá-los até a delegacia. Os agentes ingressaram na casa e fizeram buscas. Não acompanhou a revista. Nunca falaram de quem são as drogas, não sabe de quem são os entorpecentes (mídia).

A versão da acusada Luana não convence.

Vejamos o teor da prova oral, contrária aos interesses da ré.

O policial militar Eliezer Pascoal disse que a equipe da Guarda Municipal fazia uma operação chamada Limeira Segura envolvendo praças e parques municipais. O local onde os acusados estavam é muito conhecido pela traficância ilícita. Os réus ficaram nervosos e incomodados ao ver a viatura policial. Fizeram a abordagem. Durante a revista encontraram um pino com o réu. Perto deles havia vinte e quatro pinos de cocaína. Indagada, a acusada disse que encontrou aquelas porções de drogas numa área verde e iria devolver. Tinha dinheiro em poder daquele casal. Encontraram cento e cinquenta reais, era dinheiro picado. Viram que os acusados ficaram nervosos durante a abordagem. Em conversa com eles notaram mais nervosismo e contradições. Os dois réus estavam parados antes da abordagem. Em frente ao local da prisão mora a mãe da acusada. Alison disse que havia acabado de chegar ao local. Luana disse que encontrou aqueles entorpecentes e o réu não tinha nada a ver com aquilo. As porções estavam no portão, perto dos dois acusados. Estavam em torno de um metro e meio deles. Havia mais duas pessoas do lado de fora da casa. Luana disse que achou aquelas drogas na área verde e seriam devolvidas às autoridades, enquanto Alison contou que havia acabado de chegar na casa da ré. Havia um pino de cocaína em poder dele. A mãe da Luana saiu da casa e pelo que viu moram de duas a três famílias, são todos parentes. Foi alegado que ninguém tinha conhecimento daquelas drogas. Quanto aos entorpecentes no portão, tiveram que fazer uso de lanterna, pegaram aquelas porções pelo lado de fora, estava no pé do portão. Não conhecia os réus até então (mídia).

O guarda municipal João Marcos de Souza Barbosa disse que houve designação de viaturas para fazer operação nas praças e áreas de lazer municipais daquela região. A operação envolveu a Guarda Civil Municipal. Havia muitos furtos e roubos naquela região, assim como uso de drogas. No deslocamento, perto de uma área de esporte, presenciaram uma pessoa numa biqueira bem conhecida dos meios policiais. Fizeram a abordagem dos acusados. Com Alison encontraram dinheiro trocado e uma porção de

cocaína. Luana só tinha dinheiro. Indagada, Luana indicou a sua residência. Numa vistoria no portão da casa dela encontraram mais 24 porções de cocaína. Indagada, Luana disse que não era dela, mas depois confirmou pois achou aquelas porções numa área verde. Alison já havia sido preso por tráfico. Os acusados estavam na residência ao lado. A residência da esquina onde foram achados os entorpecentes era o local que Luana morava. Não se recorda a quantia em dinheiro encontrada, mas eram notas trocadas. Os acusados mantinham relacionamento amoroso. Alison disse que estava separado e tentava reatar o relacionamento com Luana. Já tinha visto Luana naquele ponto de tráfico várias vezes. A acusada informou que o local dos fatos era o seu endereço. Uma senhora de idade saiu e disse que Luana morava em um dos cômodos do terreno. As vinte e quatro porções de cocaína foram encontradas no pé do portão, tiveram que fazer uso de lanterna, estava escuro, o portão estava aberto e dava para visualizar da rua, pegaram pelo lado de fora, estava no pé do portão (mídia).

A policial civil Luciana Barbieri disse que na falta de policiais femininas nos plantões noturnos de Limeira costuma prestar auxílio. Não se recorda de detalhes do caso de Luana. Fica na sua sala e a autoridade pede ajuda nos trabalhos. Realizou revista na ré (mídia).

Ressalto que o depoimento de agentes públicos neste caso é perfeitamente válido. É inadmissível alegar que seriam suspeitos. Não restou comprovada qualquer agressão, armação ou perseguição dos agentes públicos, que não tinham qualquer motivo aparente ou concreto para incriminar injustamente os acusados.

Sobre a admissibilidade de tais testemunhos, cito o seguinte entendimento jurisprudencial:

"(...) Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexiste impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE – Rel. Min. Carlos Ayres Brito – j. 05.09.06; HC 73.518-5 – Rel. Min. Celso de Mello – DJU 18.10.96; HC 70.237 – Rel. Min. Carlos Velloso – RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – j. 06.06.13; HC 177.980/BA – Rel. Min. Jorge Mussi – j. 28.06.11; HC 149.540/SP – Rel. Min. Laurita Vaz – j. 12.04.11 e HC 156.586/SP – Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho – j. 27.04.10). (TJSP; Apelação 0003912-21.2015.8.26.0635; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 23ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/09/2017; Data de Registro: 25/09/2017).

Foram arroladas testemunhas de defesa de Luana.

A testemunha Pamella Suellen Reis Candido disse que é amiga da acusada. Foi ouvida como informante. Não presenciou os fatos. Não sabe nada que desabone Luana. Nunca ouviu falar do envolvimento dela com o tráfico. Conhece Alison de vista e sabe que ele é ex-marido da ré. Não sabe se Alison já foi processado (mídia).

A testemunha Jheniffer Maria da Silva Andrade contou que é amiga da ré. Foi ouvida

como informante. Não presenciou os fatos. Sabe que Luana sempre trabalhou e nunca se envolveu com coisas erradas. Nunca ouviu falar do envolvimento dela com o tráfico e uso de drogas. Conhece Alison e sabe que os réus foram marido e mulher. Não sabe nada da vida de Alison. Luana mora com a mãe dela (mídia).

Pelo que se verifica da prova oral colhida, policiais militares e guardas civis municipais realizavam uma operação na região do Parque Abílio Pedro quando, ao avistarem os acusados em local conhecido pela traficância ilícita de entorpecentes, procederam, em fundada suspeita, a abordagem deles.

Após vistoria e revista pessoal, foram encontrados embaixo do portão da residência de Luana, sob sua guarda e responsabilidade, 24 flaconetes de cocaína e R\$40,00 em dinheiro que estava em sua posse. Quanto ao réu Alison, foram localizados em sua posse 01 flaconete de cocaína e R\$110,00 em dinheiro, totalizando R\$150,00 em espécie e 25 flaconetes de cocaína (massa líquida de 11,73g de droga).

Vale ressaltar que o local da prisão é conhecido pelo tráfico de drogas. Observa-se ainda que a denunciada Luana já era conhecida nos meios policiais, tendo sido vista diversas vezes na região conhecida como ponto de tráfico, não restando qualquer dúvida que o local é destinado para este fim.

Na esfera policial, a ré confirmou o encontro de drogas e a sua intenção de devolve-las, apresentando em Juízo versão diversa a respeito dos fatos, negando qualquer vinculação com o entorpecente e desconhecendo a sua existência.

Dessa forma, o conjunto probatório é harmônico, robusto e conclusivo quanto à autoria do crime de tráfico envolvendo a corréu Luana, haja vista a quantidade, a natureza e a forma como estavam embaladas as drogas (cocaína), o encontro de dinheiro sem justificativa, as circunstâncias da prisão e o depoimento incriminador dos agentes públicos.

Sobre o tema em comento, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo é remansosa:

"APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico ilícito de drogas - Artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006 - Absolvição ou, ainda, desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 28 da Lei de Drogas - Descabimento - Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Palavra dos policiais militares - Credibilidade - Precedentes - Destinação mercantilista do entorpecente apreendido evidenciada pelas circunstâncias fáticas da prisão - Ausência de visualização de atos de mercancia - Irrelevância - Tipo misto ou de conteúdo variado - Condenação mantida (...)" (TJSP; Apelação 0004568-50.2015.8.26.0126; Relator (a): Silmar Fernandes; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Caraguatatuba - Vara Criminal; Data do Julgamento: 18/09/2017; Data de Registro: 11/10/2017).

"TRÁFICO DE ENTORPECENTES. (...) Materialidade e autoria delitiva comprovadas, sobretudo diante dos relatos seguros dos policiais militares que participaram da diligência. Escusa ofertada pelo réu isolada no quadro probatório. Impossibilidade de desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/06. Condenação mantida (...)" (TJSP; Apelação 0000137-25.2017.8.26.0571; Relator (a): Tristão Ribeiro; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapetininga - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 01/03/2018; Data de Registro: 01/03/2018).

"APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - INOCORRÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA BEM DEMONSTRADA, EM RELAÇÃO AO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS - PALAVRAS DOS AGENTES DA LEI QUE MERECEM PRIMAZIA NA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO, INCONSISTENTE A NEGATIVA DE AUTORIA - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, LOCAL DA ABORDAGEM, CONHECIDO PONTO

DE VENDA DE ENTORPECENTES, MODO COMO OS ESTUPEFACIENTES ESTAVAM EMBALADOS, QUANTIDADE SIGNIFICATIVA E NATUREZA ALTAMENTE NOCIVA COMPATÍVEIS COM O TRÁFICO(...) (TJSP; Apelação 0002975-45.2014.8.26.0344; Relator (a): Ivana David; Órgão Julgador: 9ª Câmara Criminal Extraordinária; Foro de Marília - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 15/09/2017; Data de Registro: 26/09/2017).

Segundo entendimento do saudoso Luiz Flávio Gomes:

"Para se concluir pela prática do crime de tráfico, não basta, em princípio, a quantidade (ou qualidade) da droga apreendida. Deve-se atentar, ainda, para outros fatores, tais como o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente (art. 52, I)" (GOMES, Luiz Flávio e CUNHA. Rogério Sanches (Coordenadores). Legislação Criminal Especial. Volume 6. São Paulo: Editora RT, 2009).

Não se exige a existência do efetivo comércio para a configuração do crime do artigo 33, caput, da Lei de Drogas. Basta a guarda, o transporte, o trazer consigo, ou a manutenção em depósito, com a finalidade de distribuição ou de entrega a terceiros para que o crime se consuma.

A lei penal pune a mera finalidade (intenção) mercantil da posse e da guarda da droga como tráfico consumado. O mero fato de o agente guardar ou ter em depósito drogas, ainda que a mando de terceiros, mesmo que sem intuito de lucro, configura o crime de tráfico de drogas, pois o tipo penal prevê como tráfico as condutas de guardar e ter em depósito, ainda que gratuitamente (art. 33, caput, Lei de Drogas).

Por se tratar de crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública, de modo que é condenável a simples possibilidade de distribuição, gratuita ou onerosa, do entorpecente.

Em comentários ao artigo 33 da Lei de Drogas, o saudoso Luiz Flávio Gomes preleciona:

"(...) Deve ser lembrado que algumas modalidades são permanentes, protraindo o seu momento consumativo no tempo e no espaço (p.ex., expor à venda, trazer consigo, manter em depósito, guardar etc.). A multiplicidade de condutas incriminadas parece inviabilizar a tentativa (...)" (GOMES, Luiz Flávio et al. Nova Lei de Drogas Comentada Artigo por Artigo: Lei 11.343/06 de 23.08.2006. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006).

Por outro lado, não é caso de reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j" (calamidade pública), do Código Penal. Não há provas de que a ré Luana tenha agido para se aproveitar da situação de calamidade pública causada pela pandemia do COVID-19. O delito de tráfico foi cometido em circunstâncias normais, motivo pelo qual afasto o reconhecimento da agravante.

A respeito do assunto, cito os seguintes julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça afastando a incidência da agravante em questão:

"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DECORRENTE DA PRÁTICA DO CRIME EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE. PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE NÃO POSSUEM NEXO DE CAUSALIDADE COM A SAÚDE PÚBLICA. RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA. AFASTAMENTO PELO ATUAL ORDENAMENTO JURÍDICO VIGENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO CONCESSIVA DA ORDEM QUE SE IMPÕE. 1. É assente neste Superior Tribunal o entendimento de que o atual ordenamento jurídico não admite a responsabilidade penal objetiva, circunstância que autoriza a concessão liminar da ordem nos casos em que a ofensa ao citado postulado se mostra manifesta.

2. Evidenciado, no caso, que o reconhecimento da agravante decorrente do estado de calamidade pública, ocasionado pela pandemia do novo coronavírus, não possui nenhum nexo com o crime praticado, inviável sua incidência, sob pena de violação à culpabilidade, em seu sentido principiológico. Precedente. 3. Agravo regimental improvido". (STJ, AgRg no HC 669.508/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021).

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. ROUBO SIMPLES. AGRAVANTE DO CRIME PRATICADO EM ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE O AGENTE SE PREVALECEU DESSA CIRCUNSTÂNCIA PARA A PRÁTICA DO DELITO. AGRAVANTE AFASTADA, COM A CONSEQUENTE REDUÇÃO DA PENA E ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A incidência da agravante da calamidade pública pressupõe a existência de situação concreta dando conta de que o paciente se prevaleceu da pandemia para a prática delitiva (HC 625.645/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 04/12/2020). No mesmo sentido, dentre outros: HC 632.019/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 10/2/2021; HC 629/981/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 9/2/2021; HC 620.531/SP, Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 3/2/2021. 2. Hipótese em que a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea j, do Código Penal foi aplicada apenas pelo fato de o delito ter sido praticado na vigência do Decreto Estadual nº 64.879 e do Decreto Legislativo nº 06/2020, ambos de 20.03.2020, que reconhecem estado de calamidade pública no Estado de São Paulo em razão da pandemia da COVID-19, sem a demonstração de que o agente se aproveitou do estado de calamidade pública para praticar o crime em exame, o que ensejou o respectivo afastamento, com o redimensionamento da pena e o abrandamento do regime inicial. 3. Agravo regimental não provido". (STJ, AgRg no HC 655.339/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 19/04/2021).

"Na hipótese, a agravante do art. 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, em tese seria cabível em desfavor do paciente, em face da crise causada pela pandemia, de ordem, econômica, social e sanitária, já que o crime foi cometido na vigência do Decreto Legislativo 6/2020, de 20/03/2020. Todavia, a despeito da prática do crime em ocasião de calamidade pública e do desvalor, sem dúvida, da conduta do paciente, não é suficiente, a meu sentir, a existência do Decreto que reconheceu o estado de calamidade pública para incidência da aludida agravante, uma vez que é imprescindível a existência de situação concreta dando conta de que o paciente se prevaleceu da pandemia para a prática da traficância, e isso não foi devidamente demonstrado na hipótese em análise. Ademais, como bem destacou o parecer ministerial às fls. 73, grifei "A despeito da maior censurabilidade da conduta praticada no período de calamidade pública, o referido evento, por si só, não é suficiente para atrair a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, "j", do Código Penal, sob pena de responsabilização objetiva do agente." Por essas razões, entendo que deve ser afastada a agravante genérica descrita no art. 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal(...)". (STJ, HC 632.019/SP, Rel. Ministro FÉLIX FISCHER, julgado em 10/02/2021).

A tese levantada pela Defesa da ré Luana de que as drogas podem pertencer a outras pessoas que ali residem não prospera, resultando somente em alegação generalizada para se livrar da grave acusação de tráfico.

Por outro lado, a situação do acusado Alison é diversa.

Os indícios de autoria do réu no crime de tráfico de entorpecentes existentes por ocasião do recebimento da denúncia não se tornaram em prova extrema de dúvidas ao longo da instrução processual, remanescendo dúvidas quanto à destinação mercantil da droga encontrada em seu poder, dada a ínfima quantidade, compatível com a alegação de uso (1 porção de cocaína).

Ademais, a despeito do envolvimento anterior de Alison no tráfico de drogas, os

agentes públicos não flagraram a prática pelo acusado de qualquer ato de mercancia, havendo informação de que o local da prisão e de encontro dos demais entorpecentes é residência de Luana, sua ex-esposa.

Não há dúvidas de que Alison trazia consigo uma porção de cocaína, no entanto, não se pode afirmar que se destinava tal quantia à venda, de modo que o acusado pode ser usuário ou traficante. Sempre que interrogado, ele negou a traficância, confessando apenas que portava o entorpecente localizado em seu poder para seu consumo.

Nesse cenário, não se pode excluir, por completo, sua condição de usuário de drogas. Não estando suficientemente comprovado o elemento subjetivo exigido pelo tipo penal do artigo 33 da Lei de Drogas, milita em favor de Alison a dúvida, sendo, pois, de rigor a desclassificação da conduta para a figura típica do artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

Desse modo, demonstrada a parcial procedência da imputação contra os acusados, não existindo justificativas para os seus atos, passo à dosimetria das penas a serem aplicadas.

LUANA NOGUEIRA BERNARDO.

Concernente ao crime de tráfico de drogas envolvendo Luana, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 são inteiramente favoráveis, devendo a pena-base partir do mínimo legal, isto é, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

A natureza e quantidade de drogas apreendidas no caso em tela não justificam a exasperação da pena-base, já que não se trata de quantidade elevada.

Segundo entendimento firmado pelo STF em sede de repercussão geral (STF, ARE 666334 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 03/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-084 DIVULG 05-05-2014 PUBLIC 06-05-2014), fica vedada a utilização da natureza e da quantidade da droga, cumulativamente, para majorar a pena-base, na primeira fase e na terceira, para modular a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, sob pena de indevido bis in idem".

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes a serem reconhecidas, de modo que mantenho a pena acima fixada.

Na terceira e última fase, estão ausentes quaisquer causas de aumento.

Sendo a acusada primária, de bons antecedentes, não havendo prova de que integre organização criminosa, aplico a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4ª, da Lei nº 11.343/2006, reduzindo a reprimenda em 2/3 (dois terços), tornando-se definitiva a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, além de pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, sendo o caso de redução no grau máximo devido a pouca quantidade de droga apreendida em posse da ré.

O valor do dia multa será no mínimo legal.

Para que fique bem claro, na derradeira etapa do sistema trifásico, deve ser levada em consideração a causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Tóxicos, causa esta que, uma vez verificados seus requisitos, deve ser aplicada.

A esse respeito, deve ser acolhido o seguinte preceito doutrinário:

“Dispõe o parágrafo, em sua parte final, sobre condições negativas de que o agente não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Toda prova negativa é difícil, de modo que militará em favor do réu a presunção de que é primário e de bons antecedentes e de que não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa. O ônus da prova, no caso, é do Ministério Público no sentido de demonstrar a reincidência, os maus antecedentes e a participação em atividades criminosas ou organização criminosa. Não importa que a prova seja difícil para o Ministério Público. Mais difícil seria para o réu que, por sua vez, tem o direito de não ser condenado a não ser que haja prova, ou receber, sem prova, uma pena maior quando a lei permite uma pena mais branda” (GRECO FILHO, Vicente e RASSI, João Daniel. Lei de Drogas Anotada. São Paulo: Saraiva, 2008).

Considerando o posicionamento do Supremo Tribunal Federal no acórdão proferido no HC 118.553/MS, no sentido de que o delito de tráfico de drogas privilegiado não possui natureza hedionda, revejo meu entendimento para admitir à fixação de regime inicial carcerário mais brando aos condenados pela prática daquela infração penal.

De fato, o tráfico de entorpecentes privilegiado não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos.

A obrigatoriedade do regime inicial fechado aos sentenciados por crimes hediondos e aos a eles equiparados não mais subsiste, diante da declaração de inconstitucionalidade, incidenter tantum, do § 1º do art. 2º da Lei nº 8.072/1990, pelo STF, no julgamento do HC 111.840/ES.

Dessa forma, fixo o regime inicial aberto para o caso em questão (apreensão de 11,73g da droga cocaína, acondicionados em 25 microtubos).

Para a imposição de regime prisional mais gravoso do que a pena comporta, é necessária fundamentação específica, com base em elementos concretos extraídos dos autos, conforme Súmulas 440 do STJ e 718 e 719 do Colendo STF, que assim dispõem:

Súmula 440/STJ: Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito.

Súmula 718/STF: A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada.

Súmula 719/STF: A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.

No mais, diante do reconhecimento do tráfico privilegiado, aplica-se a Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime) na fixação do regime prisional, assim como as decisões dos Tribunais Superiores (STF e STJ).

Ante a quantidade da pena imposta, a primariedade e tendo em vista a decisão do STF no sentido de que o tráfico privilegiado não pode ser considerado como crime hediondo, além da natureza e quantidade de entorpecente localizada, estando presentes os requisitos que autorizam a medida, substituto a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de um salário mínimo, a ser definida em sede de execução criminal.

ALISON EDUARDO DE CAMPOS ARAUJO.

Nos termos do art. 59 do Código Penal, considerando as circunstâncias do fato, além da pouca quantidade de droga apreendida e a confissão judicial, aplico-lhe a pena

de advertência sobre os efeitos das drogas, prevista no art. 28, inciso I, da Lei nº 11.343/06.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR a acusada LUANA NOGUEIRA BERNARDO, qualificada nos autos, às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no seu menor valor, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 c/c a redução prevista no §4º do art. 33 ambos da mesma lei.

Sem prejuízo, quanto ao corréu ALISON EDUARDO DE CAMPOS ARAUJO, qualificado nos autos, DESCLASSIFICO o crime de tráfico de drogas que lhe foi imputado, condenando-o como incurso no artigo 28 da Lei de Drogas e submetendo-o à pena de advertência sob os efeitos da droga.

Ante a quantidade da pena imposta, a primariedade e tendo em vista a decisão do STF no sentido de que o tráfico privilegiado não pode ser considerado como crime hediondo, além da natureza e quantidade de entorpecente localizada, estando presentes os requisitos que autorizam a medida, substituto a pena privativa de liberdade de LUANA por duas restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de um salário mínimo, a ser definida em sede de execução criminal.

Como responderam soltos ao processo, poderão recorrer desta em liberdade.

Custas na forma da lei, observada a gratuidade processual ora concedida.

Defiro a incineração da substância entorpecente apreendida, com as cautelas de praxe, pela qual representou a autoridade policial, bem como o perdimento do dinheiro.

Após o trânsito em julgado, o nome dos réus deverá ser lançado no rol dos culpados.

P.R.I.

Limeira, 07 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA